

1500438-68.2022.8.26.0296

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Paula Colabono Arias

Comarca: Jaguariúna

Foro: Foro de Jaguariúna

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... autos que demonstrem a fundada suspeita do tráfico praticado pelo réu naquele local e que permita justificar a invasão dos policiais no domicílio, sem autorização judicial e sem consentimento voluntário do morador.

Nesse sentido, destaco recente julgado do TJSP: "Apelação. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições. Pleito objetivando a ilicitude das provas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaguariúna

Foro de Jaguariúna

2ª Vara

Rua Santo Antonio de Posse, 259, Jaguariuna-SP - cep 13911-016

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500438-68.2022.8.26.0296 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500438-68.2022.8.26.0296

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2121836/2022 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 24755944 -

DEL.POL.JAGUARIUNA, 2121836 - DEL.POL.JAGUARIUNA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSE OSVALDO MONTEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Colabono Arias

VISTOS.

JOSÉ OSVALDO MONTEIRO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 12, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no dia 4 de maio de 2022, por volta das 18h30, na Rua Dois, 14, Bairro Recanto Camanducaia, nesta cidade e comarca de Jaguariúna, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega ilícita ao consumo de terceiros, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 15 porções de maconha, pesando 195g, e 36 microtubos contendo cocaína, pesando 38g, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 26/27, o auto de constatação preliminar de substância às fls. 23/24 e os laudos químico-toxicológicos às fls. 96/98, 99/101 e 102/104, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, possuía, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal e regulamentar, um revólver, marca Taurus, calibre

32, arma de fogo de uso permitido, bem como 16 munições íntegras, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 26/27 e laudos periciais às fls. 114/117 e 118/120. A denúncia foi recebida em 16 de junho de 2022 (fls. 160/161).

O réu foi citado (fls. 188) e apresentou defesa (fls. 133/136).

Em audiência virtual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, três de defesa e o réu foi interrogado (fls. 194).

Por fim, em memoriais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, com o reconhecimento da reincidência e fixação do regime prisional fechado (fls. 194).

A defesa, por sua vez, alegou, preliminarmente, a nulidade da apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo, porque efetivada em invasão de domicílio, sem autorização do morador ou ordem judicial e, quanto ao mérito, requereu improcedência da ação penal, com a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28, caput, da Lei 11. 343/2006.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar arguida pela defensora deve ser acolhida e, por conseguinte, é o caso de absolvição do réu, uma vez que o flagrante do réu e apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo foram manifestamente irregulares.

O STF, ao julgar o Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral, assentou a seguinte tese: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. STF. Plenário. RE 603616/R0, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral Tema 280) (Info 806).

Ademais, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento relevante na proteção da inviolabilidade de domicílio, estabelecendo que "a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo".

Nesse julgado, o STJ firmou algumas conclusões sobre o tema:

- 1) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
- 2) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada.
- 3) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.
- 4) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo.
- 5) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. STJ. 5ª Turma. HC 616.584/RS, Rel. Min. Ribeiro

Dantas, julgado em 30/03/2021. STJ. 6ª Turma. HC 598051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

No caso em exame, depreende-se do conjunto probatório apresentado na instrução que não havia fundada suspeita apta a justificar o ingresso dos policiais militares no domicílio do réu, sem ordem judicial, tampouco houve consentimento prévio e voluntário do morador. Vejamos.

Ao ser interrogado, o réu negou a prática do delito, disse que tinha uma única porção de maconha de, aproximadamente, 50 gramas para seu consumo e que a arma era para sua proteção, já que reside em área de mata. Já sobre a cocaína, alegou que o policial militar tirou do colete para incriminá-lo, pois esse pediu dinheiro ao réu para "deixar quieto". Alegou que no dia dos fatos estava no bar comprando um refrigerante e ao retornar para casa os policiais já se encontravam dentro de seu quarto. Enfatizou que o vídeo da autorização de entrada dos policiais foi gravado no interior de sua residência sob ameaça dos policiais. Explicou que trabalha por empreitada, que, em média, cobrava 5 mil reais por alicerce, 7 mil reais pelo acabamento, 13 mil reais para levantar paredes e 5 mil reais para fazer um telhado. Disse que o dinheiro era guardado no guarda-roupas, que ao chegar em casa os policiais já tinham revirado tudo e, inclusive, foram levados 16 mil reais de sua casa. Por fim, frisou que ganha bem, iria comprar uma caminhonete para trabalhar melhor, que não passa necessidade e tampouco tem tempo para traficar.

Ao prestar depoimento em juízo, o policial Gabriel relatou que houve uma denúncia anônima via Copom, a qual relatava que um indivíduo, cujo apelido era Fumaça, estava praticando tráfico de entorpecentes em sua residência, mencionando que em frente a citada casa havia dois veículos estacionados, um Fusca e um Monza. Relatou que na residência não havia portão e que ao baterem palma ninguém respondeu, tendo o acusado chegado ao local posteriormente e, questionado, disse aos policiais que dentro da residência havia certa quantidade de entorpecentes para seu uso, autorizando a entrada deles no local. Afirmou que, em busca realizada na presença do acusado, foram localizadas maconha, cocaína e, numa caixa dentro do guarda-roupas, um revólver e munições calibre 32, além de R\$ 76,00, tendo o acusado confessado informalmente o tráfico de entorpecentes. Asseverou, por fim, que a gravação autorizando a entrada dos policiais foi feita no muro do lado de fora, onde havia luz.

O policial militar Sechinatto confirmou o relato do colega e acrescentou que no quarto do acusado, ao lado da televisão, foram localizadas 15 porções de maconha, no guarda-roupas dentro de uma caixinha foram localizados 36 pinos de cocaína, um revólver calibre 32 e 16 munições de calibre 32, além de 76 reais em dinheiro. Afirmou que o réu confessou informalmente que estava vendendo os entorpecentes, pois estaria passando necessidade, bem como implorou aos policiais que não o prendessem. Ressaltou que o acusado já era conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes, assim como o local, onde havia um traficante grande do PCC, tio Chico. Por fim, asseverou que o vídeo autorizando a entrada dos policiais foi feito no muro do lado de fora da residência.

A testemunha de defesa Alessandra contou que reside próximo a casa do acusado e que ele trabalhava como pedreiro. Narrou que no dia dos fatos, uma terça-feira, por volta das 19h15, estava na companhia do acusado, conhecido também como Fumaça, e de seu filho pois iriam jantar juntos, quando o réu saiu para comprar um refrigerante e os policiais chegaram e entraram na casa. Disse que não acompanhou a busca na residência do réu e que sabe que ele é usuário de maconha, mas que não vende entorpecentes. Acrescentou que ao lado da residência do acusado tem um portão e o muro do lado de fora não é pintado, tampouco iluminado.

Já a testemunha Ana, vizinha do acusado e proprietária do bar onde o réu estava comprando refrigerante, disse que tudo aconteceu por volta das 20h. Disse que o réu é pedreiro, que entrava cedo e saía tarde do serviço e que nunca teve motivos para desconfiar que ele estivesse traficando drogas, já que sua casa não é movimentada.

A testemunha de defesa Juliana, também vizinha do acusado, disse que ele é pedreiro e foi contratado em novembro para construir a casa de sua mãe, trabalhando diariamente na obra das 08h às 17h e o pagamento era feito em dinheiro. Falou que o acusado é usuário de maconha e nunca o viu usando cocaína ou bebida alcoólica, bem

como nunca viu nenhum movimento suspeito na casa do réu.

Veja-se que a diligência dos policiais militares na residência do réu decorreu, somente, de uma denúncia anônima ao COPOM informando que o acusado praticava tráfico de entorpecentes na frente da residência dele e que, logo após tal denúncia, que sequer foi juntada ao inquérito, os policiais, sem fazer qualquer campana a fim de constatar movimento típico de comércio de entorpecentes, ingressaram na residência e, após o réu chegar ao local, já que estava no bar ao lado, colheram o consentimento dele dentro da própria residência.

Neste caso, em se tratando de denúncia anônima genérica da prática de tráfico de entorpecentes na frente ou dentro da residência, havia tempo hábil para que os policiais relatassem o fato para a autoridade policial e para esta solicitar um mandado de busca e apreensão, ou mesmo para que fosse feita campana no local ou sucinta investigação, o que não ocorreu.

Além disso, a primeira testemunha de defesa ouvida confirmou que o réu estava no bar, comprando refrigerante, quando os policiais militares ingressaram na residência dele, e as demais afirmaram que o réu exercia atividade lícita. Aliás, a advogada de defesa juntou fotografia do local dos fatos, onde é possível verificar que há um porão de madeira na residência, onde o bar fica ao lado, e que, de fato, a gravação do suposto consentimento do réu foi feito pelos policiais já dentro da residência.

Vale ressaltar, também, que os policiais militares, ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, afirmaram que se dirigiram para o local apontado na denúncia recebida pelo COPOM e se depararam com o investigado na via pública, quando então ele disse que tinha uma pequena quantidade de entorpecentes para o próprio consumo, autorizando a entrada deles na residência (fls. 09 e seguintes). Já em juízo, os mesmos policiais informaram que a residência não havia portão e que ao baterem palma ninguém respondeu, tendo o acusado chegado ao local posteriormente e, ao ser questionado, disse que dentro da residência havia certa quantidade de entorpecentes para seu uso, autorizando a entrada deles no local.

Ou seja, diferente do relatado quando da prisão em flagrante, o réu não estava na via pública, na frente da residência, quando da chegada dos policiais, mas chegou posteriormente à residência, após o ingresso dos policiais no local, o que corrobora a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório de que foi surpreendido com os policiais dentro da sua casa e seu consentimento, quanto ao ingresso no domicílio, não foi espontâneo.

Destarte, ainda que as 15 porções de maconha e 36 porções de cocaína fossem destinadas a venda, não há qualquer elemento nos autos que demonstrem a fundada suspeita do tráfico praticado pelo réu naquele local e que permita justificar a invasão dos policiais no domicílio, sem autorização judicial e sem consentimento voluntário do morador.

Nesse sentido, destaco recente julgado do TJSP: "Apelação. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições. Pleito objetivando a ilicitude das provas obtidas a partir de denúncia anônima e posterior ingresso em domicílio, por policiais militares, com a consequente absolvição por falta de provas.

Possibilidade. Apelante que teria mantido em depósito 95 porções de crack (11,59 g), 12 porções de cocaína (3,97 g) e 29 porções de maconha (55,99 g), para fins de traficância, bem como possuía um revólver, calibre 38, com numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos intactos, e cinco munições, calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ilegalidade da atuação policial no caso concreto. Diligência policial iniciada por meio de "denúncia anônima" genérica, não esclarecida quanto à sua origem e existência. Entrada na residência da recorrente que ocorreu sem nenhuma diligência prévia de investigação policial, como o acompanhamento do movimento no imóvel por meio de campanas, com registro documental, ou mesmo o flagrante de uma atividade de mercancia ilícita, não se demonstrando sequer a urgência necessária para a excepcional invasão da residência naquele momento específico por parte dos policiais militares. Dúvidas acerca da existência e regularidade do suposto consentimento oferecido pela apelante, quanto à entrada dos policiais no local. Circunstâncias do caso concreto que, em seu conjunto, demonstram a ilicitude da

entrada dos policiais no apartamento da recorrente e, por consequência, da apreensão dos entorpecentes, da arma de fogo e respectivas munições. Precedentes do STF e do STJ. Assim, tendo em vista a inadmissibilidade de utilização de tais elementos de prova ilícitos, resta frágil e insuficiente o acervo probatório amealhado para comprovação dos crimes, sendo de rigor a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Recurso provido (TJSP; Apelação Criminal 1500037-10.2021.8.26.0618; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pindamonhangaba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2022; Data de Registro: 07/08/2022)

Portanto, uma vez irregular as provas obtidas pela invasão de domicílio, resta frágil e insuficiente o acervo probatório amealhado para comprovação dos crimes, sendo de rigor a absolvição do réu.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO JOSÉ OSVALDO MONTEIRO na acusação contida na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Declaro o perdimento da arma de fogo, munições e entorpecentes, em favor da União, pois objetos ilícitos.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de levantamento do valor apreendido em favor do réu.

P.I.

Jaguariuna, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA